

1500695-37.2021.8.26.0326

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andre Gustavo Livonesi

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... regimental no agravo em recurso especial. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. [...] Ausência de apreensão de drogas com o agravante. Conduta típica por existirem outros elementos de provas que comprovem o crime de tráfico. [...] 6. Não há se falar em nulidade pela ausência de laudo de exame toxicológico, visto que existem vários laudos de exames acostados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

2ª Vara

Praça José Firpo, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucelia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia2@tjsp.jus.br

1500695-37.2021.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500695-37.2021.8.26.0326

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CLEBERSON LUÍS DE LIMA

Vistos.

CLEBERSON LUÍS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Representante do Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque, segundo a denúncia, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 14h00min, dentro da Penitenciária de Lucélia, guardava e mantinha em depósito, para fim de entrega a terceiro, 18 (dezoito) invólucros de maconha, droga de uso proscrito no País, embalada, com massa líquida de 5,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, o denunciado cumpria pena na Penitenciária de Lucélia/SP e na data dos fatos, durante uma blitz na cela 03 do Setor de Triage, foram encontrados 18 (dezoito) invólucros contendo erva aparentando ser maconha, ao lado do vaso sanitário, tendo Cleberson assumido a propriedade dos materiais.

O acusado foi citado (fls. 166/167) e seu Defensor apresentou resposta à acusação (fls. 188/190).

O Ministério Público manifestou-se sobre a defesa apresentada, requerendo o prosseguimento da ação penal (fls. 206/209).

A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 211/213 e afastada a possibilidade de absolvição sumária foi designada audiência de instrução, na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação, e interrogado o acusado.

Foi interposto embargos declaratórios em face da r. decisão de fls. 211/213, alegando contradição no indeferimento do pedido de perícia datiloscópica (fls.

221/222), o qual não foi acolhido (fl. 223).

Em Audiência, foi colhida a prova oral e interrogado o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público ressaltou os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários e também pela própria testemunha da defesa, uma vez que evidenciaram a responsabilização do réu pela droga apreendida, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. Terminou requerendo a condenação do réu.

Em sede de memoriais, a Defesa do réu, por sua vez, alegou a inexistência de provas robustas de autoria e materialidade suficientes para o crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

No caso em exame, a ação penal é procedente, vez que o acervo probatório formado no curso da instrução mostrou-se idôneo e apto a sustentar o decreto condenatório do réu.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

A prova da materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), termo circunstanciado (fls. 13/69), o qual inclui o laudo pericial que resultou positivo para a droga apreendida (fls. 65/67) bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa.

O agente penitenciário JOÃO PAULO PAES, em juízo, relatou que foi feita uma revista na cela onde o acusado estava alocado. Foi encontrada droga no banheiro, ao lado do vaso sanitário, dezoito porções. Havia outras porções escondidas, mas foram localizadas por outros agentes. O acusado assumiu a propriedade da droga. Não presenciou nenhuma ameaça para assumir ser o proprietário da droga. Não se recorda de algum detento ter dito que comprou droga do acusado. Na cela havia entre 10 e 15 presos naquela época.

O agente penitenciário ALDO JOSÉ LUNARDELLO, em juízo, relatou que houve uma revista na cela da triagem e foram encontradas porções de droga em alguns lugares, entre eles próximo ao vaso sanitário, encontrada essa por João Paulo. O acusado assumiu a propriedade desta droga. Não possui problema com o acusado. Presenciou o encontro da droga e o acusado ter assumido a propriedade da droga. Na cela tinha entre 10 e 15 detentos naquela data. Além do sanitário, foram encontradas drogas em pertences de outros três detentos.

O agente penitenciário LUCIANO VALDEMIRO DE LIMA, em juízo, disse que foi feita uma revista na cela da triagem e o funcionário João Paes encontrou os invólucros de maconha nos pertences do acusado, tendo ele assumido a propriedade. No mesmo dia, foi encontrada droga nos pertences de Alex. Não fez busca nos pertences do acusado.

O agente penitenciário GILBERTO CARLOS PERNOMIAN, em juízo, relatou que o Diretor de Plantão e o Substituto de Disciplina pediram para fazer a revista na cela n. 3 da triagem. Os detentos dificultaram a realização da vistoria, ficando na frente da cela. Na revista da terceira cama, dentro de uma mochila, foram encontradas as porções de maconha, que Jeferson assumiu ser de sua propriedade. Foram encontradas drogas em três locais e três detentos diferentes assumiram a propriedade. Também foi encontrada droga no banheiro e na cama do lado direito. Não se recorda do resultado da apuração da falta grave. Não efetuou busca pessoal ou em objetos pessoais do acusado.

A testemunha de defesa ALESSANDRO MARTINS SAMPAIO, em juízo, disse que foi encontrada a porção de droga dentro da cela. Não conhece o acusado. No dia dos

fatos, viu o acusado negando ser o proprietário da droga. Depois disso, um deles disse que comprou algo dele, mas não viu qualquer negociação. O depoente foi colocado como usuário de droga, mas nega tal situação. As pessoas foram retiradas da cela, feita revista pessoal, passaram pelo scanner. Os agentes perguntavam quem eram os donos das porções de droga encontradas. O depoente e mais três foram separados e levados para apuração disciplinar. Jeferson teria dito que comprou droga do acusado. Presenciou o acusado perguntando qual foi o depoimento dado por cada detento, tendo ouvido Cleberson dizer "você disse que comprou algo meu", tendo ele dito que "eu disse a verdade, comprei por R\$ 100,00".

O réu CLEBERSON LUÍS DE LIMA, ao ser interrogado, contou que tem 37 anos, em união estável, tem doze filhos e é autônomo. Ocorreu a saída temporária, retornou, passou pelos procedimentos de segurança e ingressou na unidade. Estava havendo quarentena em razão da COVID. Quando faltavam três dias para sair da quarentena, ocorreu o fato. Foi feita a revista na cela. Chamaram o nome do depoente e de Jeferson. Foi encontrada droga na terceira cama, numa bolsa e ainda no banheiro. Negou ser o proprietário da droga. Nenhum detento foi questionado pelo depoente sobre a compra de droga. Já teve desentendimento anterior com o agente Aldo.

Em que pese a negativa do réu, as testemunhas ouvidas em juízo, agentes penitenciários na época do delito, narraram o fato de maneira inequívoca, sendo uníssomos em relatar que o acusado assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes que foram apreendidos na cela que habitava.

Os relatos dos agentes penitenciários apresentaram coerência desde a fase policial, não havendo nada que ponha em dúvida a lisura de suas condutas. Não há que se questionar o valor probante de seus depoimentos.

Além de tudo, a própria testemunha da defesa afastou a credibilidade da negativa do réu por ter relatado que houve uma discussão entre o Cleberson e outro presidiário, sendo que este afirmou ter comprado droga do réu, indicando que de fato ele tinha a droga apreendida em seu poder e era envolvido com o tráfico de drogas.

Anoto que a ausência de apreensão de drogas no poder do acusado não resulta, necessariamente, na atipicidade da conduta, se houver outros elementos aptos a comprovar o crime.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente:

Penal e processo penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. [...] Ausência de apreensão de drogas com o agravante. Conduta típica por existirem outros elementos de provas que comprovem o crime de tráfico. [...] 6. Não há se falar em nulidade pela ausência de laudo de exame toxicológico, visto que existem vários laudos de exames acostados ao feito. 7. As instâncias de origem, com base no acervo fático-probatório, condenaram o agravante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, valendo destacar que ele encontrava-se encarcerado, sendo, pois, muito difícil que se encontrasse drogas em seu poder. No entanto, ainda assim liderava um esquema organizado para a comercialização de entorpecentes. Ademais, consoante o informativo 501 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. [...] (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 16/6/2020)

No mais, para a configuração do delito de tráfico de drogas, irrelevante que a droga não tenha chegado a seu destinatário ou o agente tenha sido pego em pleno ato de comercialização. Sendo delito de ações múltiplas, basta a prática de uma delas para sua consumação.

Diante do conjunto probatório (quantidade de entorpecentes, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão e local onde foram encontrados), é evidente a prática delitiva pelo réu, no interior de estabelecimento prisional, sendo perfeitamente enquadrado no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena:

Primeira fase: Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ele ostenta condenações criminais anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma será considerada para fins de maus antecedentes (processo 0008911-17.2014.8.26.0032 - fl. 164), e a outra será sopesada em fase própria - reincidência - a fim de não se incorrer em bis in idem. Fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda fase: Presente a agravante da reincidência (processo 0008911-17.2014.8.26.0032- conforme certidão de fl. 158), razão pela qual exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), a totalizar 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira fase: Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a ser de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, que torno definitiva.

Regime inicial de cumprimento: Considero como adequado o regime inicial fechado, diante do montante de pena aplicado e da reincidência delitiva.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista a quantidade de pena aplicada e a natureza da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR CLEBERSON LUÍS DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.

Faculto ao acusado recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Transitado em julgado: i) expeça-se guia de execução definitiva; ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem; iii) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ; e iv) expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucélia, 10 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Gustavo Livonesi

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA